

1500143-24.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK GOMES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

PATRICK GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500143-24.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 22/03/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-24.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK GOMES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

PATRICK GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 01/02, a saber:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 18h30, na avenida Marginal Anchieta, 8895, bairro Jequitibá, Itanhaém, PATRICK GOMES DOS SANTO, qualificado às fls. 04/05, trazia consigo 13 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha; 27 porções de crack e 56 porções de cocaína, bem como guardava, nas proximidades, 200 pinos de cocaína e 74 pedras de crack, drogas destinadas à venda, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado trazia consigo 13 porções de maconha; 27 porções de crack e 56 porções de cocaína, ocultas por dentro da cueca, ao tempo em que guardava 200 pinos de cocaína e 7 pedras de crack dentro de uma mochila, escondidas nas proximidades do local onde estava posicionado para vendê-las. Ocorre que, ao perceber a aproximação de policiais, o denunciado tentou fugir correndo, contudo, foi preso em flagrante, seguindo-se a apreensão dos entorpecentes e de R\$ 232,00, fruto do tráfico de drogas.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 09/11), o auto de exibição e apreensão (fls. 12/15), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente apreendida (fls. 16/17), a nota de culpa (fl. 24) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 48/49). Ulteriormente, foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 195/197).

Por ocasião da audiência de custódia (fls. 53/54), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 55/58).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida, determinando-se, na sequência, a citação do acusado na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, c/c art. 55 da Lei nº 11.343/06. Citado, apresentou resposta escrita às fls. 150/159, por intermédio de defensora dativa. Às fls. 164/166, por não ser o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento por plataforma remota, conforme disciplinado pelo Provimento CG 284/2020.

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do réu Wesley e Marcos, as testemunhas arroladas pela defesa do réu, Lucas e Luiz, bem como interrogado o réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo em que a defesa requereu a rejeição da denúncia, sob a égide anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Patrick Gomes dos Santos nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 16/17) e, principalmente, pelo laudo toxicológico de fls. 195/197, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 26,7g de Tetraidrocanabinol e 81,9,7g de cocaína. A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado na fase indiciária (fls. 06/07) e em Juízo, o acusado informou ter vindo de São Paulo para Itanhaém para ficar na casa de seu

amigo, Juninho. Alegou que já foi preso no Estado de Goiás pelo crime de tráfico de entorpecentes, permanecendo encarcerado por um ano e quatro meses, encontrando-se em liberdade há dois ou três anos. Disse que na fatídica data estava na Avenida Marginal, próximo ao quiosque, onde estava comercializando entorpecentes, trazendo, consigo, uma pequena sacola preta com 15 pedras de crack, 10 pinos de pó e 10 baranga de maconha. Em seu poder ainda havia cerca de R\$ 240,00 auferidos por meio do comércio proscrito. Relatou que, ao avistar a viatura policial, evadiu-se, porém logo foi alcançado pelos milicianos, os quais lograram encontrar as drogas e o dinheiro. Informou que os policiais vistoriaram as proximidades e encontraram, próximo ao quiosque, uma mochila, cuja propriedade desconhece.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal,

“o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.”

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras da inculpada e as demais provas amealhadas.

O policial militar Wesley, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 04), aclarou que na fatídica data estava em patrulhamento pelo local apontado na denúncia, na companhia do Cabo PM Lopes, sendo que, na altura do número 8.800 da Avenida Marginal Anchieta, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Este, ao perceber a presença dos policiais, começou a correr, todavia logo foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado escondido na cueca do réu uma sacola, na qual havia 56 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, 13 porções de maconha e R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais). Ao averiguarem as proximidades de onde o acusado estava, encontraram uma mochila com 200 pinos de cocaína e 74 pedras de crack. Informou que Patrick de imediato confessou estar comercializando entorpecentes, ressaltando, no entanto, que a mochila não lhe pertencia, e sim a outro indivíduo que dormia ali, não localizado.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Marcos, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 05).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97; pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os policiais, ao chegarem no local dos fatos, avistaram o inculpado. Este, ao notar a presença da viatura, evadiu-se. Posteriormente, ao ser abordado, os agentes estatais encontraram diversos entorpecentes e R\$ 232,00 em seu poder. E, ao averiguarem as proximidades, encontraram uma mochila com diversos

entorpecentes.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade da droga encontrada (26,7g de tetrahydrocannabinol e 81,9g de cocaína) e as circunstâncias que envolveram o caso (a forma como estava acondicionado o entorpecente e a apreensão de dinheiro com o réu), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se que parte dos entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Não bastasse todo o cenário enredado, em poder do réu foram encontrados R\$ 232,00 reais em espécie (fls. 12/13).

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se podem imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros. Veja-se que os depoimentos se mostraram harmônicos, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes (tetrahydrocannabinol e cocaína).

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo”(STJ; HC27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006)

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.”(STJ; HC34374/MS, Min. Gilson Dip p; Quinta Turma; DJ 01/07/2004)

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexó etiológico a os unir com o crime apurado.

Pois bem, no caso dos autos, tenho de ser o caso de se determinar o perdimento, do valor apreendido de R\$ 232,00 reais (fls. 12/13), pois o contexto em que fora localizado deixa evidente, portanto, que o lucro foi adquirido proveniente da traficância, tratando-se, portanto, de proveito auferido.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram azealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias e as consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão.

Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública), exaspero a pena em 1/6. Conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228, "de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

Presente, todavia, a atenuante da confissão espontânea, ex vi do artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal (vide depoimento colhido em Juízo), pelo que compenso-a com a agravante alvitrada.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. E isso porque, além de se tratar de um direito subjetivo, verifica-se que o acusado é primário, portador de bons antecedentes. Embora efetivamente responda o acusado por outros feitos, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Assim, o mesmo raciocínio deve balizar a análise da aplicação do redutor em questão.

Portanto, fica então operada a diminuição na 1/2, dada à diversidade e nocividade da droga. A este respeito, observo que:

"o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade, a despeito da primariedade do réu, deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada à diversidade e nocividade da droga.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individualizados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a

restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, foram encontradas mais de uma espécie de entorpecente, o que revela nocividade em seu comportamento, não compatível com a branda possibilidade de concessão dos benefícios referidos (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inc. III, do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado PATRICK GOMES DOS SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 55/58, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se o ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fls. 12/13, R\$ 232,00).

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhem-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84.
4. Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fls. 12/13, R\$ 232,00).

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA